

1502838-98.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... transtornos familiares e fomento ao tráfico de drogas. Materialidade de autoria bem comprovadas. Laudo pericial, termo circunstanciado e depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão. Depoimento policial válido. Ausência de inconsistências e máculas nas declarações. Condenação mantida. Pena bem dosada. Apelo improvido. (TJSP; Apelação 0000379-55.2016.8.26.0397; Relator ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, ., JARDIM DOUTOR ANTONIO PETRAGLIA - CEP 14402-000, Fone: (16) 2103-9133, Franca-SP - E-mail: franca2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - ASSENTADA

Processo Digital nº:

1502838-98.2021.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3061200/2021 - DISE-DEL.SEC.FRANCA, 19237026 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIEZER MARZAGÃO OLIMPIO

Vítima e Terceiro Interessado Certo:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Em 19 de maio de 2022, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, nos termos do Comunicado CG 284/2020 e mediante prévia concordância das partes, foi realizada audiência virtual sob a presidência do Excelentíssimo Juiz Sr. Dr. EWERTON MEIRELIS GONCALVES, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal. Participaram do ato o representante do Ministério Público, Dr. Yuri Borges de Mendonça e o Defensor Público, Dr. Douglas Schauerhuber Nunes.

Demais participantes:

o Réu, ELIEZER MARZAGÃO OLIMPIO, preso por outro processo, apresentado em sala de audiências virtuais da Penitenciária de Franca. Início da gravação 01:23, Final 02:20.

Foi-lhe assegurado o direito de entrevista com seu defensor, em reunião virtual apartada e privativa, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P.

a testemunha comum, PM ESDRAS OLIVEIRA DE SOUZA, Início da gravação 00:05, Final 01:18.

Quanto à testemunha comum PM OLDAIR PROCHNOW, O representante do Ministério Público e o Defensor desistiram de sua oitiva. A desistência foi homologada pelo MM. Juiz.

Em seguida, com as formalidades legais, passou o MM. Juiz de Direito a tomar o depoimento da testemunha através do sistema virtual e, em seguida, foi interrogado o réu.

As imagens e áudio captados através do programa Microsoft Teams em audiência, encontram-se armazenados no presente termo, e também, serão arquivados em DVD no cartório.

Na fase do art. 402 do C.P.P., nada foi requerido.

Na apresentação de seus memorias, pelo representante do Ministério Público foi dito:

O denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do art 28 da Lei 11343/06 porque, segundo consta, no dia e local apontado na denúncia, trazia consigo para uso próprio o entorpecente apreendido pelos agentes policiais no mesmo dia. Regularmente processado, houve a instrução nesta data havendo o policial militar confirmado em Juízo, e sob o crivo do contraditório, a prática delitiva. Outrossim, o próprio acusado confessou a posse da droga alegando que se destinava a seu próprio consumo. Sob outro prisma, o laudo confirma a presença da substância entorpecente no material apreendido. Desta feita, havendo comprovação da materialidade delitiva, da autoria e demonstrada a tipicidade, o Ministério Público aguarda a condenação do réu com a observância de seus antecedentes na dosimetria da pena.

Na apresentação dos seus memoriais, a Defesa assim manifestou :

O acusado foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, eis que no local, dia e horário mencionados na exordial acusatória, supostamente trazia consigo, para consumo pessoal, pequena quantidade de droga.

Todavia, o réu deve ser absolvido sumariamente, pois a conduta a ele imputada é atípica, dada a indisfarçável inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Vale salientar, de pronto, a seriedade da tese ora ventilada, eis que o Supremo Tribunal Federal, ao realizar o exame prévio de admissibilidade do Recurso Extraordinário nº 635.659, interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, reconheceu que a matéria tem repercussão geral, extravasando o âmbito de interesse das partes naquele processo.

O legislador ordinário, quando redigiu o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sancionando as condutas de quem possui ou detém de qualquer forma drogas para seu consumo próprio, extrapolou seu poder, ferindo preceitos constitucionais que condicionam a atividade legiferante.

De fato, o artigo 5º, X, da Constituição Federal, positivou o direito fundamental de todo e qualquer cidadão à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Esse direito tem reflexos na esfera penal, na medida em que somente é legítima a relativização de uma garantia individual fundamental se ela for necessária para que outra pessoa usufrua de seus direitos, compatibilizando, portanto, interesses antagônicos dos componentes da sociedade.

Nessa linha de inteligência, voltando os olhos para o Direito Penal, não se pode afastar da premissa de que a opção legislativa por sancionar determinadas condutas apenas se coaduna com o espírito de nossa Carta Magna se estas mesmas condutas, quando praticadas, tiverem o condão de lesionar bens jurídicos alheios. É dessa premissa que se extraem os princípios da lesividade e da alteridade, vetores do Direito Penal moderno e frutos das concepções racionalistas que inspiram a Ciência Jurídica.

Por influxo de tais princípios, proíbe-se a aplicação de sanção a quem pratica conduta que não ocasione lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico de terceiro. Afinal, só é relevante para o Direito Penal o resultado que repercuta na esfera de interesses alheios. Se o agente ofende tão-somente bens jurídicos próprios, se autolesionando, não deve haver crime.

O usuário de drogas lícitas ou ilícitas afeta, com sua conduta, a própria saúde, de sorte que não ofende ou ameaça bem jurídico de terceiro.

O argumento de que a infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas é crime de perigo abstrato que tem como bem jurídico a saúde pública não se sustenta. O próprio tipo penal estabelece os limites de sua incidência, punindo aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo "para consumo próprio" delimita com exatidão o âmbito da lesividade, impedindo qualquer interpretação diversa que ultrapasse as fronteiras da autolesão.

O fato de a droga se destinar ao consumo pessoal, por si só, já não se compatibiliza com o perigo para interesses jurídicos alheios, sendo de total irracionalidade sustentar que o bem jurídico tutelado é a saúde pública, quando claramente é a integridade física do usuário. O contrário seria transformar o usuário em potencial traficante, ferindo não só o princípio da lesividade, como a própria presunção de inocência.

Ora, se quem faz uso de drogas, lícitas ou ilícitas, prejudica apenas a si mesmo, não há razão alguma para a intervenção estatal sancionatória, que acarretará a relativização ou vulneração do direito fundamental constante no artigo 5º, X, da Constituição Federal, bem como constituirá ofensa aos princípios da lesividade e da alteridade.

Lembre-se que os princípios ora invocados incidem sem qualquer discussão nos casos em que não há pressões ideológicas ou midiáticas, como, por exemplo, nos de tentativa de suicídio, autolesão corporal, danos ao próprio patrimônio etc.

O Direito Penal, conforme ensina Nilo Batista, não pode ser utilizado para reprimir comportamentos tidos como imorais se eles não lesionarem os direitos de outras pessoas:

"Este princípio transporta para o terreno penal a questão geral da exterioridade e alteridade (ou bilateralidade) do direito: ao contrário da moral – e sem embargo da relevância jurídica que possam ter atitudes interiores, associadas, como motivo ou fim de agir, a um sucesso externo – o direito 'coloca face-a-face, pelo menos, dois sujeitos'. No direito penal, à conduta do sujeito autor do crime deve relacionar-se, como signo do outro sujeito, o bem jurídico (que era objeto da proteção penal e foi ofendido pelo crime – por isso chamado de objeto jurídico do crime). Como ensina Roxin, 'só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos de outras pessoas e não é simplesmente um comportamento pecaminoso ou imoral' [...] À conduta puramente interna, ou puramente individual – seja pecaminosa, imoral, escandalosa ou diferente – falta lesividade que pode legitimar a intervenção penal." (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal brasileiro. 5 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 91).

Deve-se ter em conta, ademais, que todos os seres humanos capazes têm (ou deveriam ter) o direito de gerenciar autonomamente a própria vida, livres de qualquer ingerência moralista por parte do Estado.

Salvo de Carvalho, em obra específica sobre o tema, afirma com propriedade:

"Nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser aos sujeitos determinados padrões de comportamento que reforçam concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da

recepção constitucional dos valores do pluralismo e da tolerância à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade.”(CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil. Estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 256).

Alice Bianchini também é enfática:

"[...] sempre que o direito criminal invade as esferas da moralidade ou do bem-estar social, ultrapassa seus próprios limites em detrimento de suas tarefas primordiais [...] Pelo menos do ponto de vista do direito criminal, a todos os homens assiste o inalienável direito de irem para o inferno à sua própria maneira, contanto que não lesem diretamente." (BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 33).

A possibilidade de o ser humano fazer escolhas, por mais esdrúxulas ou inexplicáveis que elas possam parecer aos espectadores, deve ser encarada como uma prerrogativa inalienável dos indivíduos, impedindo que uma pessoa seja punida em razão de seu estilo de vida - por exemplo, pela religião que professa, por sua orientação sexual, ou, ainda, por suas convicções ideológicas - haja vista que o modo como o sujeito optou viver não repercute diretamente na esfera de direitos alheios.

É com base nos argumentos acima expostos que as cortes constitucionais latino-americanas vêm declarando a incompatibilidade da incriminação da posse de drogas para consumo pessoal com suas Cartas magnas, a exemplo do que fizeram a “Corte Suprema de Justicia de La Nación Argentina” e a “Corte Suprema de Justicia” da Colômbia.

Mas não é só. Os tribunais pátrios também vêm adotando o entendimento ora esposado. Veja-se:

“1-A traficância exige prova concreta, não sendo suficientes, para a comprovação da mercancia, denúncias anônimas de que o acusado seria um traficante. 2 - O artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é inconstitucional. A criminalização primária do porte de entorpecentes para uso próprio é de indisfarçável insustentabilidade jurídico-penal, porque não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil.” (TJSP, Apelação Criminal nº 993071265373, Relator José Henrique Rodrigues Torres, 6ª Câmara de Direito Criminal “C”, j. 31.03.2008) (grifo nosso).

“PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO (CONDUTA GUARDAR). CANNABIS SATIVA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. ART. 16 DA LEI 6.368/76. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE, HUMANIDADE E OFENSIVIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA (ART. 386, III, DO CPP). 2) RECEPÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DOLO. O elemento subjetivo do tipo, no crime do art. 180, caput, do CP, é a vontade consciente de adquirir, receber, conduzir ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime. Inexistindo prova do conhecimento prévio da procedência ilícita da coisa, não se caracteriza o ilícito penal. ABSOLVIÇÃO MANTIDA (ART. 386, VI, DO CPP). Apelação improvida.” (TJRS, Apelação Criminal nº 70008952129, 6ª Câmara Criminal, j. 12.08.2004).

Assim, ante a evidente inconstitucionalidade da criminalização da posse de entorpecente para uso próprio, é atípica a conduta do acusado, razão pela qual requer-se seja ele absolvido, nos termos do artigo 386, III, do CPP.

Após a apresentação de memórias, o MM. Juiz proferiu a sentença:

Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Decido.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

Demonstra-se a materialidade do delito pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e exame químico toxicológico. Induvidosa também a autoria.

O próprio acusado confessou a posse da droga. Conquanto fosse suficiente a confissão do acusado para fundamentar um decreto condenatório, tem-se que restou ela corroborada pelos demais elementos probatórios.

A alegação defensiva sobre atipicidade do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 não merece guarida, porquanto todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui um risco potencial para a sociedade e deve ser punido de forma adequada.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. Posse de drogas para uso próprio. Artigo 28, caput, da lei nº 11.343/06. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Confissão do acusado respaldada pelos relatos dos guardas. Inaplicabilidade dos princípios da insignificância e da intervenção mínima. Precedentes dos Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Pena de advertência adequada. RECURSO DESPROVIDO. (Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca: Santos; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/03/2017; Data de registro: 17/03/2017).

Da mesma forma, não comporta acolhimento a arguição defensiva quanto à inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas para consumo próprio. Victor Eduardo Rios Gonçalves e José Paulo Baltazar Junior assim lecionam sobre o tema:

“Existem, ainda, aqueles que sustentam que a incriminação ao mero porte de entorpecente para uso próprio seria inconstitucional, por ser vedado ao Estado interferir na liberdade de as pessoas fazerem o que quiserem com a própria saúde. (...) Deve-se lembrar, porém, que o porte de entorpecente representa um perigo para toda a coletividade, e não apenas para aqueles que portam e fazem uso da droga. A pessoa dependente, além de danos à própria saúde, pode ficar violenta, causar vários tipos de acidentes e, até mesmo, em face da necessidade de sustentar seu vício, cometer crimes contra o patrimônio ou de outra natureza. Por essas razões, entendemos não haver qualquer inconstitucionalidade no dispositivo.”

Assim também entendeu o Excelso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em um caso semelhante (grifo nosso):

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo defensivo. Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inocorrência. Dispositivo penal que tutela a saúde pública. Efeitos nocivos das substâncias entorpecentes. Vício, dependência, transtornos familiares e fomento ao tráfico de drogas. Materialidade de autoria bem comprovadas. Laudo pericial, termo circunstanciado e depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão. Depoimento policial válido. Ausência de inconsistências e máculas nas declarações. Condenação mantida. Pena bem dosada. Apelo improvido. (TJSP; Apelação 0000379-55.2016.8.26.0397; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Dessa forma, apesar de a defesa ter suscitado a atipicidade da conduta, com fulcro nos princípios da intervenção mínima, não lesividade da conduta e da alteridade, há que se fazer a ressalva de que não comporta acolhimento o pleito defensivo pelas

razões já expostas nessa decisão.

Portanto, a condenação do réu é medida de rigor.
Atendendo as circunstâncias do caso, fixo-lhe a pena de medida educativa de advertência sobre os efeitos das drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar ELIEZER MARZAGÃO OLIMPIO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 28 da Lei 11.343/06, à pena de medida educativa de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas.

Tendo as partes renunciado ao direito de recurso, transito em julgado nesta oportunidade, fica o sentenciado advertido sobre os efeitos das drogas, no presente ato.

Assim, julgo extinta a pena pelo cumprimento. Oficie-se ao IIRGD. Intime-se o réu para que indique pessoa autorizada para retirar o valor apreendido. Oficie-se ao D.P. de origem para que sejam destruídas a droga remanescente(contraprova), bem como os demais objetos apreendidos. Conferidos e regularizados, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas. NADA MAIS. Eu, Valeria Pires Bortoletto Busquilha, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: assinado digitalmente